

1501909-20.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... viram o acusado sozinho no ponto de trafico, que ele tentou se evadir quando viu a viatura e que dispensou parte da droga que trazia consigo, bem como que o restante dos entorpecentes foram localizados bem próximo de onde ele inicialmente estava, local bastante conhecido como ponto de trafico. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados por policiais são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501909-20.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/001403

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2339044/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 21930045 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 3577/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2339044 - 02º D.P. PIRACICABA, 3577/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ALBERTO FERREIRA RISSATO

Réu Preso

Aos 19 de abril de 2022, às 15:15h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: MARCOS ALBERTO FERREIRA RISSATO - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC JOEL VASCONCELOS DE LIMA - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC JOSÉ ROBERTO SANTOS ROCHA - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas GC JOEL VASCONCELOS DE LIMA e GC JOSÉ ROBERTO SANTOS ROCHA.

Após, o réu MARCOS ALBERTO FERREIRA RISSATO foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MM^a. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "MARCOS ALBERTO FERREIRA RISSATO, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 96//98. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 134), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 139/143), sendo a denúncia recebida (fls. 144/146). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), pelas fotografias de fls. 41/42, e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 119/121. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O guarda municipal Joel Vasconcelos de Lima, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que, estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, momento em que avistaram o acusado que, ao ver a aproximação da viatura, começou a correr na direção oposta. Os policiais perseguiram o acusado com a viatura e, durante o trajeto, viram que ele havia dispensado algo no solo. Relatou que o local é bastante conhecido pelo tráfico de drogas. Feita a abordagem e realizada a revista pessoal, na posse de Marcos Alberto fora encontrado apenas dinheiro em espécie. Ao retornar para o local onde viram o acusado dispensando um objeto, encontraram 09 (nove) porções de cocaína. No local onde o acusado fora visto originalmente – ponto de partida de sua corrida em direção oposta a dos policiais – os guardas municipais encontraram mais 87 (oitenta e sete) porções de cocaína, embaladas de forma idêntica àquelas que o acusado dispensou durante sua tentativa de fuga. Afirmou que o acusado estava sozinho no local onde foi avistado inicialmente, e que os entorpecentes localizados neste local estavam bem próximo de onde ele inicialmente estava. No mesmo sentido foram as palavras do guarda municipal José Roberto Santos Rocha, que confirmou que os entorpecentes dispensados pelo réu durante sua tentativa de evasão estavam embalados de forma idêntica aos entorpecentes localizados próximo de onde ele inicialmente estava e foi avistado, esclarecendo que tais entorpecentes estavam em um buraco no chão acerca de vinte metros do local onde foi avistado. Esclareceu ainda que o acusado estava sozinho no momento em que foi visto e que ele, ao ser indagado, informalmente confessou que estava traficando no local, já bastante conhecido como ponto de trafico. . Por fim, interrogado, o réu negou a prática delitiva, afirmando que foi até o local para comprar drogas para seu uso, tendo comprado nove pinos de cocaína. Disse que pediu também porções de crack e ele foi buscar . Alegou que ficou esperando onde estava o restante da droga do traficante, momento em que os guardas chegaram. Alegou que assustou-se e então correu. Disse que cada porção de crack e de cocaína custavam cinco reais, e as nove porções lhe custaram sessenta reais, porem não tinha entregue o pagamento para o traficante porque "não tinha certeza se ele iria voltar". Assim, em que pese a alegação do acusado, tem-se que a mesma não tem como prevalecer, eis que restou isolada no álbum probatório. De fato, é certo que sequer os valores que tinha consigo, o quanto alegou que havia ganho de seu cunhado e o quanto cada porção de droga custava coincidiram, evidenciando a falácia de sua versão. De outra banda, os guardas ouvidos foram coesos ao afirmar que viram o acusado sozinho no ponto de trafico, que ele tentou se evadir quando viu a viatura e que dispensou parte da droga que trazia consigo, bem como que o restante dos entorpecentes foram localizados bem próximo de onde ele inicialmente estava, local bastante conhecido como ponto de trafico. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados por policiais são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na

verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Passo à dosimetria da pena do réu. Quanto à aplicação da reprimenda, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, haja vista que o acusado ostenta várias condenações anteriores, com trânsito em julgado datados de prazo superior ao período depurador da reincidência. Neste sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÕES EXTINTAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O agravo regimental não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Precedentes. 2. O agravante não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário. 3. Condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 925.136, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ. 02/09/2016)". Na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente específico, possuindo condenação anterior pelo mesmo crime. Na terceira fase, ante a reincidência e os maus antecedentes, inaplicável o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende, EM SEDE PRELIMINAR, que as provas obtidas nos autos, em especial as substâncias entorpecentes encontradas pelos Guardas Municipais são ilícitas, eis que a abordagem e a prisão do acusado decorreram de autoridades incompetentes. Com efeito, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 144, § 8º, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sendo o referido dispositivo reproduzido de forma idêntica na Constituição do Estado de São Paulo. Portanto, de acordo com as referidas disposições, vislumbra-se que a atual ordem jurídica contempla quais são as específicas atribuições da Guarda Municipal, órgão ao qual incumbe a defesa e proteção dos bens, serviços e instalações em âmbito municipal. Ou seja, as Guardas Municipais não têm status de polícia ostensiva, função esta que cabe a Polícia Militar do Estado de São Paulo. No caso em tela, verifica-se que houve flagrante invasão de competência material, pois a Guarda Municipal atuou como se fosse polícia ostensiva. Nesse aspecto, cumpre mencionar que os Guardas, de forma ilegal, abordaram o acusado sem que qualquer situação de flagrante delito estivesse visível, ainda que fossem autoridades incompetentes para tanto. Essa função, todavia, não incumbe aos Guardas Municipais, mas à Polícia Militar. Na realidade, os Guardas Municipais, diante do fato, deveriam ter acionado o órgão competente para atender à ocorrência. Na atual ordem jurídica, existe a polícia ostensiva, representada pela Militar, e a polícia judiciária, representada pela Civil. Assim, os Guardas jamais poderiam ter atuado como se possuíssem aptidão para tanto. Há, no caso em comento, evidente invasão de competência administrativa, de

índole constitucional, o que enseja a ilegalidade do ato (prisão em flagrante) e de todas as provas carreadas aos autos, visto que elas são provenientes, todas, de atos dos aludidos Guardas Municipais que atuaram como polícia ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Neste sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Ação Penal - Desarmamento - Guarda Municipal - Ação de polícia ostensiva - Ilegalidade - Apelo provido para absolver o acusado." (TJSP, ACri nº 990.09.226504-0 - 2ª câmara de direito criminal - origem: Piracicaba/SP, julg. 1º/02/10); "Apelação Criminal Tráfico de entorpecentes - Prisão dos réus efetuada por Guardas Municipais - Afirmação dos servidores da realização de campana para confirmar o crime - ilegalidade da ação reconhecida - Admissão, no caso presente, da existência de prova que contamina a ação penal Apelo provido para absolver os réus." (TJSP, ACri nº 0032340-54.2011.8.26.0602 - 2ª Câmara de Direito Criminal - origem: Sorocaba/SP, julg. 12/11/2012). Inclusive, nas palavras do Ilustre Desembargador relator da Apelação Criminal nº 0032340-54.2011.8.26.0602, cuja ementa se encontra acima transcrita e que teve origem na Comarca de Sorocaba/SP, onde também é usual que a Guarda Municipal exerça as tarefas da polícia ostensiva, defendeu, com grande propriedade, o Dr. Almeida Sampaio: "Fica delineado, de maneira bastante evidente, portanto, que, dentro da divisão das atribuições das Polícias, somente à Militar é outorgado constitucionalmente o poder de exercer o policiamento ostensivo, cabendo tão-somente à Guarda Municipal a proteção de seus bens, serviços e instalações". E ainda: "Em razão da Constituição de 1988, todos os entendimentos jurisprudenciais e a legislação que não se coadunem com a norma perderam sua validade. Enquanto não ocorrer alteração dos dispositivos acima transcritos, fica rejeitada a validade da ação de Guarda Municipal que, em ação de policiamento ostensivo, efetua diligências para prender eventual traficante.". Por fim, é cediço que qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão em flagrante e, por isso, em tese, a Guarda Municipal também teria esse poder. Contudo, o que não é permitido é que uma Instituição que tem por função a proteção do patrimônio público se utilize de um poder que não possui e atenda ocorrências, realize investigações e efetue abordagens, a fim de efetuar uma prisão em flagrante. Todavia, se superada a preliminar, QUANTO AO MÉRITO, as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Joel, GCM, declarou que estavam em patrulhamento quando, ao chegarem no local dos fatos, avistaram o réu. Ao ver a viatura, ele começou a correr. Perseguiram o acusado e, durante a fuga, visualizaram o momento em que ele dispensou um objeto ao solo. Conseguiram deter o réu e, com ele, encontraram apenas dinheiro. Todavia, recuperaram o objeto dispensado durante a fuga e constataram que era entorpecentes. Posteriormente, o parceiro da testemunha fez uma varredura pelo local e encontrou mais entorpecente, que era idêntico ao dispensado pelo réu. O acusado confessou informalmente o tráfico de drogas. O réu estava sozinho. O restante do entorpecente estava próximo ao local onde o réu foi visto inicialmente. Acredita que já abordou o réu neste local. O local é conhecido como ponto de tráfico. O parceiro da testemunha pode precisar a distância entre os entorpecentes encontrados posteriormente e o local onde o réu estava inicialmente. Todas as drogas estavam embaladas de forma idêntica. A testemunha José Roberto, GCM, declarou que estavam em patrulhamento pelo bairro quando visualizaram o réu, que correu ao ver a viatura. Durante a fuga, ele dispensou um objeto ao solo. Efetuaram a abordagem do réu e a testemunha recuperou o objeto dispensado, que se tratava de cocaína. A testemunha também foi ao local onde o réu estava inicialmente e encontrou mais drogas, escondidas em um buraco. O acusado estava sozinho. As drogas estavam embaladas da mesma forma. A distância do local onde o réu foi abordado até o local onde as drogas estavam era de aproximadamente 30 metros. Não conhecia o réu antes dos fatos. O local é conhecido como ponto de tráfico. O réu, em interrogatório, declarou que foi ao local para comprar entorpecentes para seu consumo. Portava R\$ 100,00. Ia comprar 09 porções de cocaína e R\$ 60,00 de crack. Comprou a cocaína e o traficante mandou que o réu aguardasse enquanto ele ia na casa dele buscar o crack.

Enquanto aguardava, a viatura chegou. Saiu correndo porque não queria ser abordado no ponto de tráfico e perto das drogas do traficante. As drogas que os Guardas acharam pertenciam ao traficante. Estava com R\$ 100,00. Comprou 09 pinos de cocaína. Cada pino custa R\$ 5,00. O traficante estava com pouco dinheiro na mão e devolveu os R\$ 60,00 para o réu. Como não sabia se ele ia voltar com o crack, ficou com dinheiro. O crack também custa R\$ 5,00. Cada dia as drogas custam um valor (alguns dias é R\$ 5,00, outros R\$ 10,00). Não conhecia os Policiais. Trabalhava em um sítio de sua família e ganhava algum dinheiro de forma esporádica. Na época, seu cunhado lhe deu R\$ 150,00. Comprava drogas no Jardim Oriente. Não comprava drogas todos os dias, porque sua família o monitorava. Portanto, Excelência, verifica-se que o acusado nega a prática do tráfico de drogas, sendo que sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais evidências dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Guardas Municipais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança patrimonial do Município ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito do depoimento dos Guardas, não existiam sequer denúncias prévias apontando o acusado como o responsável pelo tráfico de drogas na região e não foram avistadas condutas prévias que indicassem o envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes (p. ex., recebimento de dinheiro, entrega de objetos, etc.), além de não terem sido apresentados outros indivíduos como possíveis compradores das drogas e/ou testemunhas presenciais dos fatos. Além disso, os entorpecentes não estavam sob a posse direta do acusado, mas em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo, sendo que as testemunhas sequer visualizaram o réu mexendo no ponto onde as drogas estavam acondicionadas. E a suposta confissão informal do acusado não foi confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a mera afirmação de que o local da abordagem seria um ponto de tráfico de drogas não é presunção absoluta de dedicação do réu à prática deste crime, eis que, nesses locais, circulam tanto indivíduos envolvidos com o comércio de entorpecentes quanto usuários dessas substâncias. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que

atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas, sendo que, reitere-se, não foi verificado qualquer ato efetivo de mercancia dos entorpecentes. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminosa), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFe, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda:

trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao eu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição ("O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos", in Direitos Humanos - Visões Contemporâneas, edição de Associação Juizes para a Democracia, 2001). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (ainda que informal ou extrajudicial), compensando-a com eventual agravante da reincidência, diante do caráter subjetivo e preponderante de ambas as circunstâncias; (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF - Pleno - HC nº 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

MARCOS ALBERTO FERREIRA RISSATO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 00h04, na Avenida Neuza Maria Mendes Tonin, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para fins de tráfico, 09 (nove) microtubos tipo "eppendorf", contendo cocaína, com peso líquido de 2,1g (dois gramas e um decigrama), além de manter em depósito, também para fins de tráfico, 78 (setenta e oito) microtubos plásticos tipo "eppendorf", contendo cocaína, com peso líquido de 18,5g (dezoito gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que guardas municipais realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de comercialização de entorpecentes, quando visualizaram o acusado sozinho em uma esquina. Ao notar a aproximação da viatura, o réu começou a correr na direção oposta. Diante da fundada suspeita, os guardas perseguiram o réu, que, no percurso, dispensou nove cápsulas plásticas contendo cocaína. Abordado, em revista pessoal, foram localizados R\$60,00 em dinheiro, tendo os policiais recolhido as cápsulas dispensadas pelo acusado. Dando continuidade à diligência, o local onde o acusado foi visto inicialmente foi vistoriado, localizando-se outras 78 cápsulas plásticas contendo cocaína, idênticas as encontradas na posse do acusado, que, informalmente, admitiu para os guardas que praticava o tráfico no momento da abordagem.

Posteriormente, a denúncia foi aditada para fazer constar a data correta dos fatos e quantidade de drogas registrada entre parênteses.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 135) e apresentou defesa preliminar (fls. 139/143), seguindo-se a decisão de fls. 144/146, que recebeu a denúncia.

Designada audiência, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu.

As partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal dos

réus.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls.119/121, que trouxe resultado positivo para cocaína.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu fez uso do direito de permanecer em silêncio (fls. 10).

Em juízo, negou a prática do crime. Disse que foi ao local com R\$ 100,00 para comprar nove pinos de cocaína e R\$ 60,00 de "crack". Alegou que chegou ao local e o rapaz que estava lá lhe deu as nove porções de cocaína, mas não tinha o "crack". Disse que entregou o dinheiro para o rapaz, que lhe deu R\$ 60,00 de troco. Afirmou que o rapaz falou que iria buscar o "crack" na casa dele. Então, ficou no local aguardando, mas era onde o rapaz guardava a cocaína dele. Após, os guardas chegaram, razão pela qual realmente correu. Disse que morava no sítio com seu cunhado e sua irmã. Sustentou que os ajudava no sítio, fazendo bicos, e recebia casa e comida. Afirmou que seu cunhado lhe deu R\$ 150,00 e, então, foi até a cidade. Asseverou que cada porção de cocaína e de "crack" custavam R\$ 5,00.

A versão apresentada pelo réu, porém, foi infirmada pela prova produzida.

O guarda municipal Joel relatou que estavam em patrulhamento e chegaram ao local conhecido por intenso tráfico de entorpecente. Disse que avistaram um indivíduo que, ao notar a viatura, saiu correndo. Então, decidiram abordá-lo e, durante a fuga, viram o indivíduo dispensar algo ao solo. Informou que, feita a abordagem, encontraram com o réu apenas dinheiro e constataram que ele tinha dispensado microtubos de cocaína. Atestou que, feita uma varredura, seu parceiro localizou mais entorpecentes no local onde ele estava inicialmente, idênticos aos que ele dispensou. Aduziu que ele confessou a prática do crime.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal José Roberto. Aduziu que, após, a abordagem, localizou o entorpecente que o réu tinha dispensado e, no local onde ele estava anteriormente, encontrou mais certa quantidade de entorpecente num buraco na calçada.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem guardas municipais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de guardas municipais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665).

Por fim, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que, conforme dispõe a lei, qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal). Aliás, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da prática criminosa, não pudessem tomar providências para fazer cessar a infração, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apelação nº 0019493-07.2010.8.26.0068, Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

Enfim, o fato de os guardas terem flagrado o réu dispensando nove porções de cocaína ao avistara a viatura e de terem apreendido outras 78 porções da mesma droga, escondidas na esquina onde ele estava antes de empreender fuga, todas embaladas de maneira idêntica às dispensadas pelo réu, conduz à certeza quanto à autoria.

Prosseguindo, a quantidade de entorpecentes apreendida e a forma como estavam

acondiçionados, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito. Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Anoto, para constar, que o réu não logrou apresentar justificativa plausível para estar no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, à meia-noite e não demonstrou ter renda suficiente para sustentar vício tão caro.

Observo que, embora tenha alegado que cada porção de cocaína custava R\$ 5,00, afirmou que teria pago R\$ 40,00 e recebido nove porções, o que não é verossímil. Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente traga consigo ou tenha em depósito a substância entorpecente.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta Maus Antecedentes (autos nº 0030590-53.2009, da 1ª Vara Criminal local - certidão a fls. 151/157).

De acordo com o art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência, mas podem ser consideradas como Maus Antecedentes, nos termos do art. 59 do mesmo código.

Nesse sentido decisão do C. STJ: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES.

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que à luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência mas podem ser consideradas como Maus Antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. Considerando que o ordenamento jurídico pátrio adota quanto aos Maus Antecedentes o sistema da perpetuidade, e não da temporariedade, como no caso da reincidência, é de se manter o entendimento pacificado por este Sodalício de que, mesmo ultrapassado o prazo depurador, as condenações anteriores podem ser consideradas como Maus Antecedentes.

3. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp nº 1.604.407/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 12.08.2016).

E o STF, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos Maus Antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Na segunda fase da fixação da pena, observo que o réu é triplamente reincidente, inclusive específico (autos nº 0003106-68.2006, da 1ª Vara Criminal local e autos

0017141-96.2007 e 0024651-87.2012, ambos da 2ª Vara Criminal local - fls. 110/114 e informações da F.A da VEC à fls. 99/109), razão pela qual aumento-a de um quinto, resultando sete anos de reclusão e seiscentos e noventa e nove dias-multa, no valor mínimo legal.

Inexistem causas de aumento e, por ser o réu portador de maus antecedentes e reincidente, não faz jus à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, em razão da reincidência específica e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Porque demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro o seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar MARCOS ALBERTO FERREIRA RISSATO, qualificado nos autos, à pena de sete anos de reclusão e seiscentos e noventa e nove dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, fixado o regime inicial fechado e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por

TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 18/04/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MM^a. Juíza de Direito da 4^a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]